

1500396-48.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500396-48.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096703/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 24168904 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2096703 - DEL.POL.VARGEM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor da Silva Sampaio e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

FABIO SANTOS DE ARAÚJO e IGOR DA SILVA SAMPAIO foram denunciados como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, porque no dia 07 de abril de 2022, na Rodovia BR 381, Km 7, cidade de Vargem, nesta Comarca, visando alcançar o Estado de Minas Gerais, transportavam, para consumo de

terceiros, 1430 papелotes de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar às fls.

191/192. Recebida a denúncia aos 08 de julho de 2022 (fl. 194), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fl. 237).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 267/276).

A defesa postulou a absolvição embasada na ausência de provas das autorias e na fragilidade dos depoimentos colhidos, a par da atipicidade quanto ao crime de associação denunciado (fls. 282/295).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de tráfico está plenamente comprovada.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 152/153) descreveu e concluiu que a substância analisada é cocaína, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos as autorias também se evidenciaram, não obstante as escusas inconvincentes dos acusados, que em seus interrogatórios negaram a prática da infração.

Igor disse que naquela ocasião acompanhou o coacusado Fábio até a cidade de São Paulo para que ele pudesse visitar seu filho. Declarou que ambos saíram da cidade de Extrema e foram de ônibus até São Paulo. Explicou que naquela ocasião Fábio lhe pediu emprestado sua mochila.

Contou que, enquanto permaneciam no terminal rodoviário, uma pessoa e abordou Fábio e pediu para ele que pegasse uma sacola com um casal, naquele mesmo local. Logo depois, retornaram para Bragança Paulista e, na sequência, pegaram um táxi que os levaria até Extrema. No entanto, foram abordados pelos policiais nas proximidades do pedágio. Finalizou argumentando que desconhecia que havia drogas naquela sacola que foi entregue a Fábio, não obstante ela tenha sido colocada dentro da sua mochila.

Por sua vez, Fábio declarou que é usuário de drogas há dois anos e, em decorrência do vício, possuía uma dívida. Disse que naquela ocasião estava na cidade de São Paulo para visitar seus filhos e recebeu um telefonema de uma pessoa cobrando o pagamento de sua dívida. Esta pessoa "determinou" que ele, quando voltasse da zona leste, fosse até o terminal Tiête e pegasse uma bolsa, cor preta, que seria entregue por um casal. Salientou que depois de fazer o contato e pegar a bolsa, a guardou no interior da mochila de Igor. Defendeu-se dizendo que não sabia que tinha droga no interior daquela sacola e que apenas aceitou realizar o transporte porque estava recebendo ameaças em razão da dívida de drogas.

Suas escusas não convenceram e restaram isoladas.

De proêmio, observa-se contradição entre as versões apresentadas pelos acusados, fator que retira a credibilidade de suas palavras.

Isso porque Igor mencionou que somente ficaram no Terminal Rodoviário Tiete, dali não saindo para outro lugar, e que tão logo Fábio pegou a sacola de um casal, já retornaram de ônibus com destino a Bragança Paulista.

Vejamos um trecho de seu interrogatório:

J.: Pararam na rodoviária, foram em mais algum lugar lá em São Paulo?

D.: Ah! Lá em São Paulo eu não conheço muito senhor. Eu não conheço.

J.: O senhor ficou na rodoviária ou foi em mais algum lugar?

D.: Nós ficou na rodoviária ali.

J.: E esse rapaz pôs o pacote na mochila então? O senhor viu isso? Estava junto com

ele?

D.: Não, nessa hora eu não vi.

J.: E daí pegaram o ônibus na volta pra Bragança?

D.: Isso. De Bragança nós pegou um taxi pra ir pra Extrema.

Por outro lado, Fábio narrou que estava na cidade de São Paulo para visitar seus filhos e que somente na volta é que pegou a sacola que continha as drogas, junto a um casal no terminal do Tietê.

Se não bastasse tal contrariedade, durante a etapa policial eles se calaram.

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo".

Ora, se de fato desconhecêssem a ilicitude do material que transportavam, certamente teriam declarado tal situação durante seus interrogatórios extrajudiciais. Somente em Juízo apresentaram tais versões.

Lado outro, se revela incrível a versão de Fábio no sentido de que sequer imaginava que pudesse estar transportando entorpecente, especialmente se levarmos em conta o fato de que estaria cumprindo determinação de traficantes a quem devia dinheiro, ou ainda, teria recebido o objeto de uma pessoa que sequer conhecia.

No mais, eles se escusaram da imputação através de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais lhes imputar injustificadamente tal crime.

Se não bastasse a força de convencimento insita nos argumentos expostos, corroboram a certeza das autorias os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução.

Senão vejamos.

O Policial Rodoviário Victor relatou que naquela oportunidade realizou patrulhamento de rotina nas proximidades da divisa entre os Estado de São Paulo e Minas Gerais. Em determinado momento observou um veículo taxi na cabine do pedágio. Então iniciou uma conversa com o motorista, um senhor de idade. Disse que enquanto conversava com o taxista, em nenhum momento os passageiros daquele veículo olharam para ele. Então indagou aos acusados de onde eles estavam vindo, oportunidade em que eles mencionaram que teriam ido a São Paulo para passear na rodoviária, fator que lhe causou estranheza.

Acrescentou, ainda, que ambos os acusados se encontravam muito nervosos, bem como notou que no banco detrás do veículo havia uma mochila. Salientou que nenhum dos dois assumiu a propriedade daquele objeto, razão pela qual resolveu vistoria-lo, oportunidade em que localizou grande quantidade de cocaína.

Suas palavras são confirmadas pelo policial Pedro Ivo, que de forma séria e coerente descreveu as razões que motivaram a abordagem aos acusados, asseverando a apreensão das drogas no banco detrás do veículo, no interior de uma mochila.

Narrou, ainda, que a par da droga, dentro da mochila havia um exame de covid em nome de um dos acusados e uma passagem em nome do outro envolvido, o que o levou a concluir que ambos os acusados estavam em conluio no transporte das drogas. Por fim, relatou que apurou junto ao taxista os acusados seguiam em direção a cidade de Extrema, no Estado de São Paulo.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão dos acusados tivessem qualquer motivo para imputar a eles, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade dos agentes. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a

compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial.

Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frise-se também que ambos agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a abordagem policial e revista aos agentes, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhai colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais

é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014) Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, as circunstâncias como foram surpreendidos, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenham os agentes efetuado a venda. Basta que a possuam ou tenham em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitância do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afim, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da

simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

A conduta praticada pelos acusados amolda-se perfeitamente às figuras "guardar, ter em depósito e transportar", previstas no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, bem comprovadas as autorias e materialidade da infração.

Não obstante os argumentos já expendidos em relação ao crime de tráfico, não deve prosperar a imputação de associação para tal finalidade.

Isto porque os acusados nada admitiram neste particular. Nenhum vestígio existe a respeito de uma eventual associação duradoura e estável entre eles. Os guardas nada relataram sobre a associação imputada.

O crime de associação se distingue do concurso eventual de pessoas que exige um acordo de vontades ocasional e efêmero para a perpetração de determinado crime; a associação pressupõe ajuste permanente ou estável para a perpetração de vários crimes de tráfico de entorpecentes (mínimo dois).

A propósito, dispõe o artigo 35: Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1.º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a "reiteração ou não "julgado e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33 e 34 da lei nº 11.343/2006, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição.

Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho:

"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..."(GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei n.º 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei 6368/76 - 12.ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Portanto, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris* em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

Na espécie, repise-se, inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não havendo como reconhecer, in casu, o delito de associação.

Restando, pois, sem comprovação o animus associativo mais ou menos estável ou permanente, não há que se falar em associação para o tráfico, pois, para a sua caracterização é indispensável à associação de duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; e a finalidade de traficar tóxicos, formando uma verdadeira *societas sceleris* para essa finalidade.

Não se vislumbrou a ocorrência de outros crimes de tráfico, como ainda, uma estabilidade na relação entre os acusados, razão pela qual suas absolvições se impõem.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelos condenados não justifica aumento nas penas-base.

Os antecedentes de Fábio recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de

fls. 56/58. Nesse ponto, anoto que a caducidade prevista no inciso I, do artigo 64, do Código Penal, se aplica tão somente à reincidência, de modo que, decorrido o respectivo período depurador, nada impede a consideração da condenação anterior como Maus Antecedentes, justamente para fins de exasperação da pena base. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRADO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de Maus Antecedentes, autorizando o aumento da pena-base acima do mínimo legal. 2. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (2 anos de reclusão), foram reconhecidos os Maus Antecedentes, estando justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. Incabível, também, pelos mesmos fundamentos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. 3. Agrado regimental não provido. (AgRg no AREsp 1199049/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

Nesta esteira também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

REVISÃO CRIMINAL. Latrocínio tentado. Pedido de afastamento dos Maus Antecedentes em razão do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Possibilidade de consideração de condenação como Maus Antecedentes após o período depurador da reincidência. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Não cabimento. Confissão parcial e que não foi essencial ao deslinde do feito. Pena intermediária que superou o máximo legal. Necessária a redução da pena na segunda etapa da dosimetria penal, adequando-a ao patamar máximo legal. Reprimenda redimensionada. Pedido parcialmente deferido. (TJ-SP - RVCR: 22586748920198260000 SP 2258674-89.2019.8.26.0000, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 09/06/2020, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020)

Tráfico - Artigo 33, caput da Lei de Drogas - Juízo de retratação - Artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil - Reanálise da possibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, por conta do reconhecimento do período depurador para os Maus Antecedentes do acusado - Inviável - O período depurador somente é contado para fins de reincidência, de modo que quando esta atinge o prazo de cinco anos, o réu passa a ter Maus Antecedentes - Entendimento de acordo com o Princípio da individualização da pena - Acórdão mantido. (TJ-SP - APR: 00002065920158260593 SP 0000206-59.2015.8.26.0593, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 23/07/2019, 7ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 23/07/2019)

REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade incontroversas. Inconformismo com a dosimetria. Pretensão de afastamento dos Maus Antecedentes em razão do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Inviabilidade. Período depurador de cinco anos que se aplica somente à reincidência. Cabível o pedido de afastamento do aumento operado na segunda fase da dosimetria. Decurso do quinquênio depurador. Pena redimensionada. Pedido revisional parcialmente deferido. (TJ-SP - RVCR: 22479320520198260000 SP 2247932-05.2019.8.26.0000, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 09/06/2020, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020)

Furto Qualificado Tentado - Art. 155, § 4º, IV, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal - Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório - Impossível - Câmeras de segurança flagraram os réus nas proximidades da res danificada - Depoimentos dos policiais e testemunhas mostram-se seguros e coesos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório - Redução da pena-base - Incabível - O artigo 64 do Código Penal não pode ser aplicado em se tratando de

maus antecedentes - Embora após o prazo depurador o réu não possa ser considerado reincidente, a condenação será utilizada para fins de comprovar os maus antecedentes - O documento da folha de antecedentes é suficiente para atestar a existência dos maus antecedentes - Tal entendimento já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça - Pena e regime inalterados - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15003427820198260548 SP 1500342-78.2019.8.26.0548, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/02/2020)

Por sua vez, Igor não ostenta maus antecedentes e os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade dos agentes.

Os motivos e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

No entanto, levando em consideração as circunstâncias do crime, a par da quantidade da droga apreendida, em obediência ao teor do artigo 42, da Lei 11.343/2006, vemos que as penas-base comportam acréscimo por conta deste fator.

Presentes as circunstâncias judiciais acima expostas, que devem levar à exacerbação das penas-base, fixo as penas de Fábio em 07 (sete) anos de reclusão e 700

(setecentos) dias-multa, e as penas de Igor em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa. O valor do dia-multa será fixado no patamar mínimo legal.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.

Na etapa final a causa especial de aumento denunciada deve incidir.

É certo que os condenados transportavam a droga entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, caracterizando o tráfico entre tais unidades da federação. Assim indicam os depoimentos existentes nos autos, que comprovam que eles estavam seguindo rumo ao Estado de Minas Gerais.

Logo, as penas serão acrescidas de $1/6$ (Fábio = 7 anos + $1/6$ = 8 anos e 02 meses/700 dias + $1/6$ = 816 dias-multa/Igor = 6 anos + $1/6$ = 7 anos de reclusão/600 dias + $1/6$ = 700 dias-multa).

Anote-se que, muito embora o coacusado Fábio seja tecnicamente primário, sua folha de antecedentes indica que ele já foi condenado por sentença transitada em julgado, com cumprimento da pena há mais de cinco anos (fls. 56/58). Muito embora o crime objeto destes autos tenha sido praticado após o prazo depurador, é ele possuidor de maus antecedentes.

Destarte, não obstante não seja possível sopesar tal condenação para considera-lo reincidente, ela pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, ante a ausência de um dos requisitos previstos no § 4º, qual seja, não se dedicar às atividades criminosas. A par disto, a expressiva quantidade de droga apreendida evidencia a sua dedicação à atividade criminosa do tráfico.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Penas. Aumento da pena-base. Necessidade. Maus antecedentes configurados. Existência de anterior condenação definitiva do apelado por tráfico de drogas. Circunstância que impõe, ainda, o afastamento do privilégio e a fixação do regime inicial fechado. Parcial provimento do apelo ministerial. (TJ-SP - APR: 15017190820188260132 SP 1501719-08.2018.8.26.0132, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 25/06/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/06/2020)

TRÁFICO DE DROGAS - Apelo Ministerial - Afastar privilégio - Réu portador de maus antecedentes e quantidade e variedade de drogas - Regime fechado - Recurso provido. Apelo do Acusado - Absolvição - Impossibilidade- Autoria e materialidade suficientemente demonstradas - Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas - Inviabilidade - Recurso improvido. (TJ-SP - APL:

00040388920148260220 SP 0004038-89.2014.8.26.0220, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/06/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para porte de drogas para o consumo

pessoal - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos - Validade dos depoimentos dos agentes públicos - Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Condenação bem lançada - PENA - Diversidade e quantidade de drogas, além dos maus antecedentes, que justificaram elevação da básica - Redução, na sequência, frente à menoridade relativa - Majorante prevista no art. 40, III cuja natureza é objetiva - Precedentes - "Privilegio" inaplicável, frente aos maus antecedentes - Regime inicial fechado único adequado - Eventual detração cuja competência para apreciação é do Juízo da Execução - Pena superior a 04 anos que não comporta substituição - Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 00001596120178260546 SP 0000159-61.2017.8.26.0546, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 11/09/2018, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2018)

Por outro lado, Igor é primário, portador de bons antecedentes criminais e, nestes autos, não se demonstrou que ele tenha envolvimento ou integre organização criminosa. Logo, amolda-se na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, suas penas serão diminuídas em 1/6, pois não existem motivos a justificar maior redução em virtude da quantidade da droga apreendida (7 anos - 1/6 = 5 anos e 10 meses/ 700 dias - 1/6 = 583 dias-multa).

Não obstante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao reconhecimento da desconsideração da hediondez ao tráfico privilegiado, o que possibilitaria o cumprimento inicial de pena em regime mais brando, in casu, ante a quantidade da droga apreendida em poder dos condenados, aproximadamente 1 quilo de cocaína, droga esta que possui elevado poder viciante, o regime inicial será o fechado, visto que, qualquer outro regime não contribuiria para a reprovação do crime e ressocialização dos agentes.

Nessa esteira:

EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA - DISCUSSÃO ENVOLVENDO O REGIME PRISIONAL CABÍVEL E A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS - BENEFÍCIOS INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE - RÉU QUE TRAFICAVA, ALÉM DE MACONHA, TAMBÉM COCAÍNA, DROGA ESTA DE EFEITOS NEFASTOS À SAÚDE DE USUÁRIOS E VICIADOS - NECESSIDADE DE ENÉRGICA REPROVAÇÃO - ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, QUE JUSTIFICA A RECUSA DOS BENEFÍCIOS, A DESPEITO DA NÃO-HEDIONDEZ DO CRIME - RECURSO DESPROVIDO. (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0100260-13.2015.8.26.0050/50000 Comarca: SÃO PAULO - Processo nº 0100260-13.2015.8.26.0050 Juízo de Origem: 8ª Vara Criminal Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal Embargante: LUCAS SANTANA BATISTA Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Embora não hediondo o crime de tráfico privilegiado, a quantidade e qualidade da droga obstam a fixação do regime mais brando. 3. Negado provimento ao recurso. (APR 10702100791806001 MG Órgão Julgador: Câmaras Criminais Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 11/01/2013. Julgamento: 13 de Dezembro de 2012. Relator: Marcílio Eustáquio Santos).

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo:

20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de

Publicação: 16/05/2014).

Os condenados não poderão apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve suas custódias, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO

DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

a) ABSOLVER FABIO SANTOS DE ARAÚJO e IGOR DA SILVA SAMPAIO, qualificados nos autos, da imputação do artigo 35, "caput", da Lei 11.343/2006, que lhes foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal;

b) CONDENAR FABIO SANTOS DE ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica;

c) CONDENAR IGOR DA SILVA SAMPAIO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica

Recomendem-se na prisão onde eles estiverem.

Declaro o perdimento dos bens apreendidos (dinheiro e celulares) com a promoção do crime, em virtude dos fundamentos utilizados nesta decisão, a teor do artigo 62, da Lei 11.343/2006.

Concedo a eles os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Com o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe, bem como adote o necessário ao cumprimento da pena e para remessa ao Senad.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 16 de setembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA